

1500782-55.2018.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que devidamente evidenciada a prática do narcotráfico.

Destarte, a forma como a droga estava acondicionada, o tipo e a grande quantidade da substância, o local e horário da abordagem, a evasiva e a maneira como ela aconteceu, o fato dele ser conhecido pelo tráfico, acoplados às demais circunstâncias do caso em exame evidenciam a finalidade do tráfico ilegal.

Desse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500782-55.2018.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500782-55.2018.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Custodio Valeriano e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ROGÉRIO CUSTÓDIO VALERIANO e NAIARA CRISTINA SILVA REIS, qualificados nos autos respectivamente a fls. 37 e 50, foram denunciados e viram-se processados como incurso, o primeiro, no artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 e a segunda como incurso no artigo 35 daquele diploma legal, porque em data incerta anteriormente, porém, ao dia 28 de setembro de 2018, em horário e local incertos, nesta cidade e Comarca de Guaíba, teriam se associado para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, do mesmo diploma legal, bem como no dia 28 de setembro de 2018, por volta das 20h20min, na residência localizada à Rua 20-B nº 1.275, Bairro José Pugliesi, nesta cidade e Comarca, o Corrêu Rogério, previamente conluído e mediante unidade de propósitos com a Corrê Naiara, teria em depósito, para fins de tráfico, 566 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 113,900 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da inicial que "Segundo se apurou, notadamente por meio de investigações (relatório de investigações de fls. 06/13) realizadas com base em dados colhidos do aparelho celular de NAIARA, os denunciados se associaram para prática do tráfico de drogas, restando acordado entre eles, após tratativas feitas por meio de mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp (fls. 10/11), que NAIARA receberia de ROGÉRIO a quantia de trezentos reais para que guardasse em sua residência trinta pacotes contendo trinta eppendorfs cheios de cocaína cada, os quais seriam posteriormente vendidas a terceiros pelo denunciado.

Também se apurou que, no dia 28 de setembro de 2018, policiais militares receberam a informação de que NAIARA (denunciada e condenada pelo fato que se passa a narrar no bojo dos autos nº 1500114-13.2018.8.26.0557) estaria guardando em sua residência grande quantidade de drogas para ROGÉRIO, vulgo 'Nego', para onde, então, se deslocaram.

Chegando ao imóvel onde NAIARA reside, foram os agentes públicos citados recebidos por esta, a qual lhes autorizou a entrada no local e indicou o exato espaço em que guardava os entorpecentes, qual seja, uma cômoda em seu quarto, onde os policiais encontraram os quinhentos e sessenta e seis eppendorfs contendo cocaína.

Os policiais também encontraram, após revista pessoal em NAIARA, um aparelho celular, o qual, posteriormente, fora objeto de investigações (fls. 61/68), havendo para tanto autorização de NAIARA (fl. 30), as quais apontam para ROGÉRIO como proprietário dos entorpecentes apreendidos.".

A denúncia, encartada em fls. 101/103, foi recebida em 12 de fevereiro de 2019 (fls. 104). Os Acusados foram citados a fls. 130 (Rogério) e fls. 158 (Naiara), apresentando defesas preliminares a fls. 167/173 (Naiara) e fls. 181/184 (Rogério), rejeitadas a fls. 191/193. Durante a instrução foi colhida prova testemunhal (fls. 318/323, 353/361 e 450) e, ao final, os Réus foram interrogados (fls. 450).

Em memoriais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, requerendo a condenação dos Acusados nos exatos termos da exordial (cf. fls. 454/462).

O Coacusado Rogério negou o teor da denúncia, asseverando que há ilegalidade na interceptação telefônica, não havendo prova apta a impor o édito condenatório, pleiteando sua absolvição (fls. 463/465).

Por seu turno, a Corrê Naiara, a fls. 466/476, arguiu preliminar e no mérito afirmou não existir prova apta para a condenação, pretendendo, pois, sua absolvição e, subsidiariamente, requereu a fixação da pena no piso, convertendo a pena corporal por restritiva de direito, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A preliminar arguida em alegações finais pela Coacusada Naiara se liga ao mérito e ali será analisada.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade está estampada no relatório de investigação de fls. 06/13, documentação de fls. 14/24, boletim de ocorrência de fls. 25/27, auto de exibição e apreensão de fls. 28/29, pelos laudos de exame químico-toxicológico a fls. 59/60 e fls. 71/73, além da prova oral colhida durante a instrução.

A autoria é certa contra os Réus.

Rogério, em Juízo, negou o teor da denúncia, dizendo nada saber sobre os fatos, conhecendo a Ré de vista, sendo usuário de maconha e, por fim, trabalha com móveis usados.

A Acusada Naiara, por sua vez, também negou o teor da denúncia, salientando que a polícia foi até sua casa, entrou sem mandato, encontraram entorpecente que era de um "careca de Uberaba", que costumava deixar em sua casa para que ela vendesse. Ademais, conhece o Réu de vista, é usuária de crack e os policiais pegaram seu celular sem sua autorização e ameaçaram lhe agredir caso não fornecesse a senha. De outra forma, a conversa que ela matinha no Facebook era com Nelson, mas não colocou seu nome porque ele era casado, dizendo que comprova produtos dele e recebia pessoalmente.

Os policiais militares Igor e Alan declararam, em uníssono, que receberam informação que a Ré estava guardando entorpecente para o Acusado, conhecido dos meios policiais pelo tráfico, dirigindo-se até a residência de Naiara, sendo por ela atendidos, instante em que ela confirmou que guardava a droga para o Réu, levando os policiais até um quartinho nos fundos, lá encontrando mais de quinhentos eppendorfs com cocaína, realizando, então, diligências para tentar localizar Rogério, sem sucesso, dizendo Alan, ainda, que o celular de Naiara foi apreendido na operação (cf. fls. 318/320 e fls. 321/323).

Maurílio, policial civil que prestou depoimento em fls. 353/361, disse que a Ré foi presa em sua residência, local onde foram encontrados pacotes de eppendorfs e a informação recebida que ela guardava para o vulgo Nego. Ademais, realizou a perícia no telefone celular da Acusada, que continha conversas entre os Acusados, sendo que "em dado momento ele pediu favor para ela guardar na casa dele malotes, trinta malotes de trinta, que no meio criminal são conhecidos em pacotes fracionados para a venda ser mais facilitada e se no caso da polícia pegar, não pegar em grande quantidade. Nessas conversas eu vi que em vários momentos que depois que ela aceitou guardar para ele, que a mãe dele estaria em casa, não poderia estar lá qualquer hora, tratando-se disso, ele prometeu para ela para vender toda essa quantidade e prometeu pagar trezentos reais quando acabasse, esses trinta malotes de trinta daria novecientos eppendorfs, mas foi apreendido quinhentos e por causa e essas conversas foi demonstrado, entre oito ou dez dias antes da prisão dela e apreensão da droga, todos os dias ele mandava gente buscar, 'hoje eu vou buscar mais cinco', um tal de Romário, entrega para o Romário, ela pergunta, 'cinco malotes?', 'vinte', essa diferença de quinhentos e sessenta e sete para novecientos que era bem plausível que teria a diferença porque ele mandava todos os dias ir buscar, fracionar a venda lá na cidade e fora as conversas desses áudios, que não tinham interesse muitas vezes, os dois conversando coisas íntimas e ela falando que estava doida, além da venda diária eles também faziam uso, então é bem possível que a diferença que foi apreendido teria ido embora no prazo de oito ou dez dias, então o teor das conversas demonstrou que realmente ela guardava drogas para ele".

A testemunha de defesa Daiana declarou que conhece a Ré da Igreja, não sabendo se ela namorou o Réu, afirmando que ela namorava uma pessoa chamada Nelson, de Miguelópolis, que é vendedor de produtos de sex shop. Ademais, o Réu mora no mesmo

bairro da depoente, mas não perto.

Da análise do contexto fático-probatório, inegável que os Acusados praticaram os crimes descritos na exordial. O teor da prova colhida dá conta da participação de ambos os Acusados na associação para o crime de tráfico de drogas e Rogério, ainda, para o tráfico propriamente dito (considerando que Naiara já havia sido condenada por este crime, conforme narrado na denúncia).

Nesse sentido, a alegação de Naiara de que os policiais a coagiram para fornecer a senha de seu telefone celular cai por terra, porque essa prova foi realizada mediante sua autorização, conforme destaca-se de fls. 18, nada havendo nos autos a corroborar sua alegação, caindo por terra a alegação comum dos doutos defensores quanto a um inexistente vício que contaminasse as provas que, portanto, são absolutamente lícitas, em especial considerando que não havia necessidade de perícia no aparelho de telefone celular, inquestionavelmente da Ré, surtindo seus regulares efeitos o já mencionado relatório de investigações.

Some-se a isso que a Ré não fez ao menos início de prova de que namorava uma pessoa Nelson, de Miguelópolis, que venderia produtos de sex shop para ela, sendo casado e, por isso, não colocaria seu nome nas conversas, o que muito longe está de representar a realidade, ônus que lhe competiria, com base no artigo 156 do Código de Processo Penal. Com a devida vênia, existisse essa pessoa, a Ré o teria certamente arrolado como testemunha.

Diz-se isso porque a robusta quantidade de cocaína apreendida com Naiara estava em seu poder a mando de Rogério, consoante a prova colhida nestes autos e acima mencionada, seja diante das testemunhas ouvidas, seja pelos dados lícitamente obtidos do telefone celular de Naiara, dando conta que ela mantinha intensa comunicação com seu comparsa, Rogério, no intento de manter em depósito a substância entorpecente descrita na denúncia.

Tais condutas, portanto, apontam que o Corréu Rogério, ao contrário do sustentando, iria utilizar o entorpecente apreendido em poder de Naiara, mas claramente sob guarda a seu pedido, mediante pagamento, para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que devidamente evidenciada a prática do narcotráfico.

Destarte, a forma como a droga estava acondicionada, o tipo e a grande quantidade da substância, o local e horário da abordagem, a evasiva e a maneira como ela aconteceu, o fato dele ser conhecido pelo tráfico, acoplados às demais circunstâncias do caso em exame evidenciam a finalidade do tráfico ilegal.

Desse modo, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo porque não podem ser descartados, notadamente porque os Réus não ofertaram qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legalidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm

convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram" (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Destarte, não restam dúvidas que no dia, horário e local indicados na inicial, os Acusados praticaram os fatos ali descritos.

De igual modo, também procede a denúncia em relação à figura tipificada no artigo 35 da Lei de Drogas. A associação para o tráfico é inconteste, pelos motivos acima mencionados, dando conta que tanto Naiara quanto Rogério se uniram para a prática do tráfico, sendo que o Acusado deixava o entorpecente com a Ré, que o escondia em sua residência, entregando-o conforme fosse necessário.

No caso em tela, desse modo, se vislumbra a reunião estável e permanente, almejando a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Oportuno consignar que, idêntico ao tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico também possui natureza jurídica de crime equiparado ao hediondo e, por isso, deve ter a mesma sistemática.

Corréu ROGÉRIO: em relação ao crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas, tem-se inicialmente que o Acusado ostenta maus antecedentes (cf. fls. 426, processo nº 0001015-63.2017.8.26.0210; fls. 430/431, autos nº 1500455-76.2019.8.26.0210), que podem ser empregados sem incorrer em bis in idem com a reincidência, que se falará abaixo, por ser fatos diversos. Ainda nesta fase, é o caso de majorar sua pena-base, considerando a grande quantidade de entorpecente apreendido para os padrões desta cidade, abundância esta que evidencia o claro indicativo de que o comércio clandestino seria abastecido por razoável período e adverte que o Réu possuía posição de destaque na traficância, o que se confirma quando se observa que ele utilizava Naiara como mera guardiã do entorpecente, razão pela qual, atendendo aos critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, com o que promovo o aumento da pena-base em 1/4 (um quarto) e a fixo inicialmente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, no menor patamar, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase aumento sua pena em 1/3 (um terço) em razão da dupla reincidência (cf. fls. 427, autos nº 0003355-19.2013.8.26.0210; fls. 429, processo nº 0004499-31.2012.8.26.0210), atingindo o patamar de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Em relação ao delito de associação para o tráfico, estabeleço a pena acima do piso legal, pelos motivos acima empregados na primeira fase do crime de tráfico, a aumentando em ¼, atingindo o patamar inicial de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, considerando sua dupla reincidência, majoro aquela pena em 1/3 (um terço), chegando à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 1.166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Promovo a soma das penas aplicadas, pois houve a existência de dois resultados pelas duas condutas distintas praticadas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, atingindo o montante de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.999 (um mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, estipulada no mínimo legal, sendo que o regime inicial para o cumprimento da pena é o fechado, por expressa disposição do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. No mais, é vedada a substituição por pena restritiva de direitos (artigo 33, parágrafo 4º, Lei 11.343/06).

O Acusado, reincidente, não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, com considerável quantidade e diversidade de drogas, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder. Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

Importante consignar que caberia à defesa a prova de que os Acusado faria jus à causa de diminuição acima mencionada, considerando-se que esta não é automática e somente de aplicação possível quando presentes os requisitos legais, forte no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, ou seja, "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo – e não há discussão a este respeito em relação ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme expressa previsão do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal -, é o fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Crim., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Ressalto, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada ao delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva

de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou a substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos objetivo (reincidentes) e subjetivo. Ressalto, quanto a este requisito subjetivo que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Corré NAIARA: Para o crime de associação para o tráfico estabeleço a pena em seu piso legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, uma vez que a Ré não possui antecedentes que possam ser utilizados para majorar sua pena, agindo com dolo normal (fls. 424/425). Torno esta pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias que justificassem a alteração do quanto acima fixado.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, deixando, contudo, de substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos ou conceder sursis porque demonstrou a Ré, ainda que primária, que estava envolvida na prática do tráfico de grandes dimensões nesta cidade, não se mostrando adequada ao caso concreto.



Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos, o que não impede a busca de reparação no Juízo Cível.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência:

a) CONDENO o Acusado ROGÉRIO CUSTÓDIO VALERIANO, com qualificação nos autos, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.999 (um mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, em regime inicial fechado e vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, como incurso nas sanções do artigo 33, caput c.c. artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; e

b) CONDENO a Ré NAIARA CRISTINA SILVA REIS, também qualificada nos autos, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se os nomes dos Réus no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Tendo em vista que os Acusados responderam em liberdade este processo, não se mostra necessária a decretação da prisão cautelar, podendo aqui aguardar o julgamento em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas as custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA